

1500101-87.2021.8.26.0240

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANNA SYLVIA RODRIGUES E SILVA

Comarca: Iepê

Foro: Foro de Iepê

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2154874/2021 - DEL.POL.IEPÊ, 18378676 - DEL.POL.IEPÊ, 200/21/206 - DEL.POL.IEPÊ, 2154874 - DEL.POL.IEPÊ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RICARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iepê

Foro de Iepê

Vara Única

Rua: Minas Gerais, 343, Iepe-SP - cep 19640-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500101-87.2021.8.26.0240 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500101-87.2021.8.26.0240

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2154874/2021 - DEL.POL.IEPÊ, 18378676 - DEL.POL.IEPÊ, 200/21/206 - DEL.POL.IEPÊ, 2154874 - DEL.POL.IEPÊ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RICARDO VINICIUS DE OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANNA SYLVIA RODRIGUES E SILVA

Vistos.

RICARDO VINICIUS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Conforme consta na denúncia, por volta das 14h30min, na esquina da Rua Treze de Maio com a Rua Guanabara, nº 77, Vila Paraná, nesta cidade de Iepê, RICARDO

VINICIUS DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 12, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, uma porção de maconha acondicionada em invólucro plástico, pesando no total 0,93g (noventa e três centigramas) de massa líquida, e um tablete de maconha também acondicionado em invólucro plástico, pesando no total 16,94g (dezesesseis gramas e noventa e quatro centigramas) de massa líquida, droga capaz de

causar dependência física e psíquica, conforme Portaria da ANVISA nº 344/1998, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 39/40, fotografias de fls. 43 e 45, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 46 e laudos periciais definitivos de fls. 92/94 e 98/100.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 6/9), em 8 de junho de 2021. Por decisão de fls. 79/83, foi decretada a prisão preventiva.

A denúncia foi oferecida em 06/07/2021 (fls. 01/05).

O réu foi notificado (fl. 130) e apresentou defesa prévia (fls. 136/140).

A denúncia foi recebida às fls. 148/150.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 198/199), foram ouvidas quatro testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais (fls. 204/212), o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia, asseverando que foram comprovadas materialidade e autoria bem como a tipicidade do art. 33 da Lei de Drogas, pois o *modus operandi* do réu, semelhante a processo anterior a que responde por tráfico, evidencia a traficância. Requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal (grau maior de reprovação, haja vista que o réu já havia sido preso em flagrante delito pela prática do mesmo crime seis meses antes dos fatos e ainda estava respondendo ao processo respectivo quando foi novamente detido - nº 1500192-17.2020.8.26.0240) e afastamento da causa de diminuição de pena do parágrafo quarto.

Em alegações finais (fls. 222/230), a Defesa alegou que não há provas suficientes da traficância, pois as testemunhas afirmaram que haviam adquirido a droga anteriormente, não foi esclarecida pela polícia a origem da denúncia e que não foram encontrados quaisquer elementos a evidenciar a traficância e sequer as condições da própria abordagem a comprovam. Requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiária e sucessivamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e aplicação do art. 33, parágrafo quarto, da mesma lei.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos fatos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 6/09), auto de exibição e apreensão (fls. 44/47), fotografias de fls. 49/50, auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 46) e laudos periciais definitivos de fls. 92/94, 97/100 e 103/105 (20,7 - vinte gramas e setenta centigramas de massa bruta e 16,94 gramas e noventa e quatro centigramas de maconha e 4,71 gramas e setenta e um centigramas de massa bruta e 0,93 - noventa e três centigramas de massa líquida de maconha, respectivamente).

A autoria também restou comprovada.

A testemunha Emerson Ricardo dos Santos Junior relatou que "estava com André e, quando encontraram Ricardo, estava aguardando o oficial de justiça para a resolução de questões com sua esposa e, em meio à conversa, decidiram ir até esquina. Que lá se sentaram e, em seguida chegaram ao local policiais, estes que realizaram a abordagem, e encontraram o entorpecente, este qual estava sendo consumido naquele momento. Questionado, negou ter adquirido a droga com Ricardo, alegando ser de André, não sabendo onde André a havia conseguido. Questionado pela defesa, relatou conhecer Ricardo e que este é usuário, esclarecendo que quem ofereceu o cigarro de maconha foi André.

A testemunha André de Oliveira Santos relatou que "saíram para apenas fumar"; disse que tinha há um tempo o entorpecente, pois é usuário, negando ter comprado a droga de Ricardo. Questionado pela defesa, respondeu que Ricardo era usuário, e que confeccionou o cigarro no local.

A testemunha Roberlley Savalio da Silva, Investigador da Polícia Civil relatou que, "ao chegar de seu horário de almoço recebeu no telefone da delegacia uma ligação anônima, relatando que o acusado estaria traficando na esquina da residência do informante, bem como estaria oferecendo entorpecentes para mais dois indivíduos. Que chegaram à delegacia os demais investigadores, sendo Alexandre e Maciel; que logo foram até o local, a fim de averiguar a denúncia recebida, haja vista que

anteriormente já haviam efetuado a prisão do acusado pelo mesmo delito, e no mesmo local. Lá chegando foram avistados o acusado e mais dois indivíduos, procedeu-se a abordagem dos mesmos, sendo que no momento da abordagem um dos indivíduos jogou no chão um cigarro, que posteriormente averiguou-se se de maconha. Que durante a revista, o acusado comportou-se de maneira nervosa, e dentro de seu tênis foi encontrado mais entorpecente. Que o acusado foi indagado se em sua residência teria mais tóxicos, momento no qual o réu mostrou-se receoso; que foram então até a residência do acusado e com a anuência de sua madrasta, adentraram até o quarto do acusado, onde lograram êxito em encontrar dentro do guarda-roupas deste, enrolado em uma coberta um tablete de maconha. Que ambos foram conduzido até a delegacia. Questionado pela acusação, pontuou que foi encontrado também na residência do acusado, embalagem vazia semelhante à encontrada dentro de seu tênis na abordagem; que não foi encontrada balança ou outro equipamento para pesagem, pois nesta urbe existe apenas a pequena traficância, não sendo necessária a pesagem do tóxico, devido ao fato de o traficante também ser usuário na maioria dos casos. Informou já conhecer o acusado de outras prisões que efetuou.

A testemunha Alexandre de Oliveira, Investigador da Polícia Civil relatou que “receberam uma denúncia que havia um rapaz fazendo uso de entorpecentes e foram até o local onde abordaram o acusado e as testemunhas, logrando êxito em localizar o entorpecente junto do acusado”. Que indagaram se havia mais na residência do réu e este titubeou, mas depois autorizou ir até lá; que ao adentrar tal imóvel foi encontrado a outra porção. Informou que o acusado já era conhecido no meio policial, inclusive já havia efetuado a prisão deste nas mesmas circunstâncias. Questionado pela acusação, respondeu que na denúncia recebida na delegacia foi dito que o acusado estava fazendo uso do entorpecente, tendo ido até o local em razão desta denúncia.

Em seu interrogatório, o réu Ricardo Vinicius De Oliveira alegou que “estava em sua casa aguardando uma visita do oficial de justiça, quando Emerson e André foram até lá, e o convidaram para fazer uso de um entorpecente que eles tinham, informa que saiu e junto de André e Emerson foi até a esquina e fizeram uso do entorpecente que André havia levado, este que já estava preparado para uso, sentaram-se na esquina e estavam fazendo uso da droga quando a polícia chegou e realizou a abordagem; que questionaram se havia mais alguma coisa, sendo encontrado 93 (noventa e três) decigramas de entorpecente em seu tênis, quantidade que iria confeccionar um cigarro, mas não o fez devido a André já ter fornecido um pronto; que era para fazer uso dentro de sua residência; que os policiais solicitaram permissão para entrar em sua residência, questionando se havia mais alguma coisa no imóvel, o acusado permitiu e no interior deste foi encontrado mais entorpecente com peso aproximado de 16 gramas. Disse que é dependente de drogas e que faz uso não somente de maconha, como também de cocaína; disse que não possui trabalho fixo, realizando apenas alguns “bicos”. Questionado pela acusação, respondeu que as embalagens plásticas encontradas se tratava de sacolas de mercado, relatando já ter sido preso anteriormente. Questionado pela defesa, respondeu que faz uso de drogas desde os 12 (doze) anos de idade, bem como costuma fazer uso do entorpecente apenas dentro de sua casa.”

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Conforme a denúncia, o réu trazia consigo uma porção de maconha escondida dentro do tênis que calçava, bem como guardava em sua residência mais um tablete de maconha escondido no meio de um cobertor que estava no interior de um guarda-roupas dentro de seu quarto.

Ainda de acordo com a denúncia, a dinâmica dos fatos se deu da seguinte maneira: os policiais receberam uma denúncia anônima de que o réu, que obteve liberdade provisória após ter sido preso em flagrante por tráfico, estaria fornecendo drogas para outros dois indivíduos próximos a sua casa. Com isso, se dirigiram ao local e avistaram André dispensando um objeto, posteriormente identificado como maconha. Ele assumiu a propriedade da droga, dizendo que era para uso próprio. Com réu, foi encontrado uma porção de maconha em seu tênis (0,93 centigramas) e em sua casa, guardado em um cobertor em seu quarto, um tablete de maconha de 16,94 gramas, dentro de uma sacola plástica, além de um saco plástico transparente.

Pois bem. Tais fatos narrados na denúncia foram parcialmente confirmados pelo depoimento dos policiais em juízo, pelas testemunhas de acusação – que igualmente informaram as circunstâncias em que se deu a abordagem policial – e pelo próprio acusado, que não nega a propriedade da droga.

Como se vê, a prova é robusta no sentido de que os policiais flagraram o réu juntamente com outros dois indivíduos que estavam fazendo uso de maconha bem como na posse de uma porção do entorpecente em seu tênis e um tablete guardado em sua casa.

Aliás, nem a defesa técnica nega tais fatos, cingindo-se a controvérsia na finalidade da posse e depósito da droga encontrada. Assim, passo à análise da tipificação da conduta.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é daqueles denominados 'tipo misto alternativo', que apresenta multiplicidade de verbos nucleares, sendo despidiêda a comprovação da comercialização, bastando a prática de quaisquer dos verbos cernes não sejam dotados do fim específico de uso pessoal. No caso em liça, o agir atribuído ao réu é “trazer consigo” e “guardar”, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.

Por sua vez, a finalidade da traficância é verificada pelas circunstâncias objetivas dos fatos, pois não é possível aferir, no íntimo do agente, a sua finalidade. Logo, a finalidade de traficância, elementar do tipo penal em questão, nos casos em que não houve a efetiva comercialização – como nas modalidades trazer consigo e guardar – é atestada pela exteriorização da conduta do agente, notadamente na forma em que foi flagrado e demais circunstâncias da apreensão da droga.

Isso se revela, por exemplo, pela quantidade de droga encontrada; forma de acondicionamento da droga (em sacolas separadas próprias para venda); encontro de utensílios tipicamente usados para traficância como sacos plásticos, plástico filme e balança de precisão; cadernetas de anotações, registros de operações anteriores em aparelho celular; presença de outros indivíduos durante o flagrante, entre outros.

No caso em tela, o Ministério Público sustenta a finalidade do tráfico no modus operandi, em relação a outro processo que o réu responde pelo mesmo delito:

“Ocorre que essa não é a primeira vez que o réu é preso em flagrante delito e processado e, curiosamente, as circunstâncias da apreensão e a forma de acondicionamento das drogas, se comparadas, são praticamente idênticas. Melhor elucidando, o réu utiliza-se de modus operandi semelhante, sempre trazendo consigo e guardando em sua residência pequenas quantidades de entorpecentes, visando assim dar embasamento às suas alegações de que é apenas um mero usuário (cf. autos nº 1500192-17.2020.8.26.0240). Todavia, as circunstâncias da apreensão denotam que as drogas eram mesmo destinadas à traficância, ainda que o réu seja também usuário, o que não exclui o delito a ele imputado”.

No entanto, a finalidade da traficância não restou suficientemente comprovada nos autos.

A alegação do Ministério Público quanto ao modus operandi, embora verossímil, é mero indício que, sem a corroboração de outros elementos dos autos, não se presta, por si só, a ensejar a condenação. Não se olvida que o indício é utilizado no Código de Processo Penal ora como prova semi-plena (baixo grau de cognição quando à profundidade) ora como prova indireta. Em sua última concepção, é gênero de prova, “ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial, ou seja partindo-se de um fato comprovado, chega-se por meio de um raciocínio dedutivo a um fato consequência que se quer provar” (em Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único, 8ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 664). No entanto, para ser utilizado como prova, devem estar preenchidas as seguintes condições: os indícios devem ser plurais e estreitamente relacionados entre si, concomitantes e o raciocínio dedutivo coerente.

No caso em tela, não foram encontrados utensílios típicos de traficância; a droga guardada estava em forma de tablete e não fracionada; a quantidade de drogas não é particularmente grande e não foi encontrado dinheiro com o réu no momento da

abordagem. Além disso, as duas testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que “estavam fumando quando a polícia chegou mas que já possuíam a droga”; “que na verdade a droga era de André”; “que já tinha o baseado mas que foi adquirido numa outra ocasião, não foi o réu quem lhe vendeu”.

Nem mesmo do depoimento dos policiais é possível concluir pela traficância, pois, conforme a denúncia, a abordagem se deu a partir de denúncia anônima – ou seja, não houve averiguação anterior ou mesmo campana um período antes da abordagem a fim de angariar mais elementos.

Aliás, o depoimento dos policiais foi divergente, pois um deles afirmou que a denúncia não foi de tráfico e sim de uso de droga, conforme se transcreve abaixo:

“(...) receberam uma denúncia que havia um rapaz fazendo uso de entorpecentes e foram até o local onde abordaram o acusado e as testemunhas, logrando êxito em localizar o entorpecente junto do acusado (...) Questionado pela acusação, respondeu que na denúncia recebida na delegacia foi dito que o acusado estava fazendo uso do entorpecente, tendo ido até o local em razão desta denúncia”.

(Alexandre de Oliveira)

Por fim, verifica-se que o telefone celular do réu foi apreendido (fl. 43), encaminhado à perícia (fls. 93/94), conforme autorização judicial à fl. 83, sobrevivendo laudo pericial às fls. 153/167, que não trouxe qualquer elemento a corroborar a acusação de tráfico.

Logo, embora seja possível que o réu estivesse traficando, o Direito Penal requer, para fins de condenação, prova robusta, ônus que compete ao órgão acusador.

Renato Brasileiro explica que o grau de convencimento que se exige do(a) magistrado(a), em sede processual penal, para conceder uma medida cautelar, para receber uma denúncia ou para condenar alguém por um fato delituoso pode ser conceituado como “critérios de decisão”, “standards probatórios” ou “modelos de constatação”, compreendidos como “o grau ou o nível de prova exigido em um caso específico, como indícios suficientes ou além de dúvida razoável” (em Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único, 8ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 674). E, na sentença condenatória, o standard probatório, por conta do princípio da presunção de inocência, é bastante elevado.

No mesmo sentido, ensina Gustavo Henrique Badaró:

“(...) não é possível que o processo penal, quanto à decisão final que realizará o juízo de mérito sobre a imputação, adote um standard de prova rebaixado. Em se aceitando a premissa de que a garantia da presunção de inocência implica o in dubio pro reo, a adoção de standards probatórios que representam inegavelmente estados de dúvida, como é o caso da mera preponderância (...) implicaria clara violação à presunção de inocência” (em Badaró, Gustavo Henrique. Epistemologia judiciária e prova penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, pag. 247).

Assim, à míngua de elementos a comprovar o tráfico e considerando que o réu estava na posse e guardava substância entorpecente (“tetrahydrocannabinol” – maconha), acolho a tese defensiva e desclassifico a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. Passo à dosimetria da pena, pois incabíveis os benefícios despenalizadores ao caso concreto (fls. 61/62). Em relação à pena a ser aplicada, considerando que os fatos foram praticados enquanto o réu estava em liberdade provisória bem como a quantidade de droga, que não é insignificante, determino a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, nos termos do art. 28, II, da Lei de Drogas. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para desclassificar a conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, condenando RICARDO VINICIUS DE OLIVEIRA como incurso no art. 28 da mesma lei, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, visto que ausentes os requisitos autorizadores da decretação de sua custódia cautelar.

Expeça-se alvará de soltura com urgência.

Condene o acusado ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; d) expeça-se guia de execução definitiva; e) autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei nº 11.343/06; f) decreto a perda dos valores apreendidos em favor da do Funad, com fulcro no art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Iepe, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA